

1503216-04.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... de estar portando arma de fogo na prática do tráfico de drogas, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, não convencendo sua versão de estar no tráfico somente há dois dias, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503216-04.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503216-04.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO VICTOR PAULO SILVA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

LUCIANO VICTOR PAULO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para fins de tráfico, 174 (cento e setenta e quatro) porções de maconha, 7 (sete) comprimidos de ecstasy, 126 (cento e vinte e seis) porções de cocaína, 180 (cento e oitenta) pedras de crack, 1 (um) galão de 5 (cinco) litros com lança perfume, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendido com o acusado um revólver de marca Taurus, calibre 38, nºZG406765, municiado com seis cartuchos íntegros, além de 1 (uma) folha de papel contendo anotações típicas da traficância de drogas, bem como a quantia de R\$106,00 (cento e seis reais), e dois telefones celulares, no bolso da

roupa que o denunciado trajava.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos quanto ao apenamento e à fixação do regime prisional.

A Defesa, em seus memoriais, deixou de requerer a absolvição do réu, diante de sua confissão. Pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública. Requereu o reconhecimento da confissão e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pediu a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelas fotografias de fls. 20, 21, e 26/40, pelo laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos. Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de drogas descrito na denúncia. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e sua filha estava para nascer. Afirmou que estava na prática do tráfico de drogas já havia dois dias, mas também fazia alguns bicos. Afirmou que o traficante ao entregar as drogas para que ele vendesse, entregava a arma de fogo também, alegando que era para as defesa em razão da concorrência com outros traficantes.

Corroborando a confissão do réu, a testemunha policial civil Bruno Tadeu de Brito Alves, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que tinham recebido informações de que no local havia a prática de tráfico de drogas, passando-se as características do traficante (usava camiseta vermelha e boné). Rumaram para o local indicado e passaram a observar o indivíduo que apresentava as mesmas características anteriormente passadas anonimamente. Observaram por várias vezes a atividade típica de tráfico de drogas que se dava na viela, a uma distância de cerca de 100 metros, do outro lado da rua, não havendo dúvidas sobre a conduta do réu. Disse que em determinado momento resolveram fazer a abordagem ao acusado.

Afirmou que quando chegaram perto do réu, anunciaram que eram policiais civis, e no mesmo momento o réu fez menção de fugir, mas optou em colocar as mãos para o alto, dizendo que estava armado. Disse que em revista pessoal encontraram um revólver calibre 38, municiado e pronto para o emprego. Afirmou que o réu estava com uma mochila também, e dentro dela tinha maconha, crack e cocaína. Também foi apreendido lança-perfume e algumas anotações em papel sobre a comercialização de entorpecentes, além de dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de, mais ou menos, R\$ 100,00. Depois disso, foi levado à delegacia. Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos e que nenhuma pessoa acompanhou a abordagem de perto. No mesmo sentido, de maneira coincidente, harmônica e coerente com o depoimento de seu colega policial, foi o depoimento da testemunha policial civil Vítor Souza de Jesus, ouvida em Juízo.

Portanto, não há dúvidas sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga e do armamento.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de

convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Os depoimentos dos agentes de segurança colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização do entorpecente e do armamento, e encontram-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, corroborando a confissão do acusado quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo.

Note-se que as testemunhas policiais civis bem relataram ter avistado o acusado, o qual apresentava as características passadas anteriormente em notícia anônima, em local também apontado na notícia anônima e já conhecido como ponto de tráfico de drogas e o viram em atitude típica de comercialização de entorpecentes, por várias vezes, momento em que foi abordado e detido na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes, de quantia em dinheiro e de uma arma de fogo, além de anotações típicas de contabilidade do tráfico.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da grande quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da

infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe. Finalmente, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, consistente no emprego de arma de fogo, também restou bem demonstrada.

Conforme se observa dos autos, especialmente pelos seguros e harmônicos depoimentos das testemunhas policiais, para a prática criminosa do tráfico de drogas, o acusado fazia uso de arma de fogo que, segundo a versão apresentada em interrogatório, era destinada a combater a concorrência com outros traficantes.

Portanto, restou bem demonstrado que o réu praticou o crime com o emprego de arma de fogo, caracterizando-se a causa de aumento de pena.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena em 1/6. Assim, fixo a pena-base, para cada acusado, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ficam as circunstâncias compensadas, mantendo-se a pena inalterada nesta etapa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, totalizando 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade da droga apreendida, a qual indica a maior periculosidade do réu e que se dedica a atividades criminosas, pois tamanha quantidade de drogas e, ainda o porte de arma de fogo, não são dados a qualquer indivíduo.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal

Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a grande quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, além de estar portando arma de fogo na prática do tráfico de drogas, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, não convencendo sua versão de estar no tráfico somente há dois dias, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pratica com o emprego de arma de fogo, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a

respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)
Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCIANO VICTOR PAULO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social.

Destaca-se, ainda, a variedade e a natureza, além da grande quantidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado, além do porte ilegal de arma de fogo, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 20 de janeiro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA